

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제03절 재판상 화해>

[기출][2013-2]소송상 화해의 의의, 요건, 효력, 하자 구제수단

《【문제2】 소송상 화해에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소송상 화해의 의의, 요건, 효력, 하자 구제수단

I. 문제의 제기

- 소송상 화해는 소송계속 중 양 당사자가 서로 양보하여 소송목적인 권리관계에 관한 다툼을 중단하고 소송을 종료시키기로 하는 합의를 말한다. 이는 소송의 주관적 해결방법으로서 판결에 의하지 않고 분쟁을 신속하게 종결짓는 기능을 한다. 소송상 화해가 성립하면 재판상 화해로서 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되므로, 그 성립요건과 효력의 범위, 그리고 화해에 하자가 있는 경우의 구제책이 논의의 핵심이 된다. 이하에서는 소송상 화해의 법적 성질, 요건, 효과 및 불복방법에 대하여 설명한다.

II. 소송상 화해의 법적 성질 및 요건

1. 법적 성질

(1) 학설의 대립

- 소송상 화해의 성질에 대하여는 사법상의 화해계약으로 보는 사법행위설, 소송종료를 목적으로 하는 소송행위로 보는 소송행위설, 그리고 사법행위와 소송행위가 병존하는 것으로 보는 양성설(병행설) 등이 대립한다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 소송상 화해를 사법상의 화해계약인 동시에 소송법상의 소송행위라고 보고 있다. 다만, 일단 화해조서가 작성되면 확정판결과 같은 효력이 생기므로 사법상의 하자를 이유로 그 효력을 다룰 수 없고 준재심에 의해서만 취소할 수 있다고 보아 소송행위적 측면을 중시한다.

2. 성립 요건

(1) 당사자에 관한 요건

- 당사자에게 소송능력이 있어야 하며, 대리인의 경우 화해에 관한 특별수권이 있어야 한다.(민사소송법 제90조 제2항)

(2) 소송물에 관한 요건

- 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계여야 한다. 따라서 처분권주의가 적용되지 않는 친족·상속법상의 권리관계 등은 원칙적으로 화해의 대상이 될 수 없다.

(3) 시기 및 방식

- 소송이 법원에 계속 중이어야 하며, 당사자 쌍방이 법원에 출석하여 화해의 의사를 표시하고 이를 조서에 기재함으로써 성립한다.

III. 소송상 화해의 효력

1. 소송종료적 효력

- 소송상 화해가 성립하여 조서에 기재되면 소송은 그 즉시 당연히 종료된다. 이는 판결의 선고와 같은 효과를 지닌다.

2. 재판상 화해의 효력

(1) 확정판결과 동일한 효력

- 민사소송법 제220조에 의하여 화해조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력과 집행력이 발생한다.

(2) 효력의 범위

- 기판력은 조서에 기재된 합의 사항에 한하여 발생한다. 판례는 화해조서의 기판력은 그 내용이 강행법규에 위반되거나 무효인 사유가 있더라도 준재심에 의해 취소되지 않는 한 당연무효라고 할 수 없다고 본다. 다만, 화해 내용이 특정되지 않거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 경우에는 효력이 부정될 수 있다.

IV. 화해의 하자과 구제수단

1. 화해의 무효·취소와 준재심

(1) 준재심의 소

- 소송상 화해에 기망, 착오 등 사법상 하자나 소송법상 하자가 있는 경우, 당사자는 재심에 관한 규정을 준용하여 준재심의 소를 제기함으로써 그 효력을 다룰 수 있다.(민사소송법 제461조)

(2) 하자의 주장 시기

- 화해조서가 작성된 후에는 별소로써 무효를 주장하거나 취소할 수 없으며, 반드시 준재심 절차를 밟아야 한다. 이는 확정판결의 안정성을 유지하기 위함이다.

2. 기일지정신청

(1) 의의

- 화해의 성립 과정에서 중대한 절차적 하자가 있어 화해 자체가 성립하지 않았다고 주장하는 경우(예 : 당사자의 불출석 등), 당사자는 소송종료의 효력을 다투며 기일지정신청을 할 수 있다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 화해가 유효하게 성립한 경우에는 준재심으로 다투어야 하지만, 화해가 부존재하거나 당연무효인 경우에는 기일지정신청을 통해 원래의 소송절차를 속행할 수 있다고 본다.

V. 결론

- 소송상 화해는 당사자의 자주적 분쟁 해결을 존중하는 제도로써, 성립 시 확정판결과 동일한 강력한 효력을 부여받는다. 이는 분쟁의 종국적 해결을 도모하는 이점이 있으나, 하자가 있는 경우에도 준재심이라는 제한된 수단에 의해서만 구제가 가능하다는 점에 유의해야 한다. 따라서 화해 조서 작성 시 당사자의 의사를 명확히 반영하고 절차적 요건을 엄격히 준수하는 것이 소송경제와 실질적 정의 실현을 위해 필수적이다.